

1501648-06.2022.8.26.0022

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Leonardi Campanella

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... informalmente que estava ali para realizar o tráfico de drogas, recebendo R\$150,00 por dia de trabalho.

Clayton Luis dos Santos, policial civil, disse que o local dos fatos era um "ponto" de tráfico, com alternância diária de vendedores de droga. Naquela data, os policiais militares avistaram ELIAS com uma sacola na mão, tentando se evadir. Abordado, o réu mostrou onde ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

1ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo-SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501648-06.2022.8.26.0022 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501648-06.2022.8.26.0022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2210497/2022 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 26528816 -

DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 2210497 - 01º D.P. AMPARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIAS JOSÉ CARVALHO CÂNDIDO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Fernando Leonardi Campanella

VISTOS.

ELIAS JOSÉ CARVALHO CÂNDIDO, devidamente qualificado (fl. 10) nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, acusado de ter, no dia 03 de agosto de 2022, por volta das 11h50min, na Rua Ludovico Altomani, próximo ao número 427, via pública,

Conjunto Habitacional Alberto Marques, nesta cidade e Comarca, trazido consigo, com o fim de entrega ilícita ao consumo de terceiros, 135 (cento e trinta e cinco) porções de cocaína, pesando 189,11g, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 120/121).

Em audiência de custódia, a prisão flagrancial foi convertida em preventiva (fls. 40/41).

A denúncia foi recebida em 24.08.2022 (fl. 62).

Devidamente citado (fl. 82), o acusado, por intermédio de sua D. Defensora nomeada (fl. 72), apresentou resposta por escrito à acusação (fls. 70/71), arrolando testemunhas.

Não sendo o caso de julgamento in limine do feito, com a absolvição sumária do acusado, determinou-se a abertura da fase instrutória (fls. 83/84), oportunidade em que foi colhida a prova oral, consistente nas oitivas de duas testemunhas arroladas em comum, sendo homologada a desistência da restante, seguindo-se do interrogatório do acusado, tudo pelo sistema audiovisual (cf. ata de fls. 115).

Em sede de memoriais escritos, o D. Promotor de Justiça requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, por entender suficientemente provadas a autoria e a materialidade delitiva (fls. 118/120). A D. Defensora, por sua vez, pugnou pela absolvição, fundamentando-a na ausência de prova segura quanto à conduta do réu voltada para o tráfico. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da imputação original para o crime de porte de entorpecente (fls. 122/125).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por intermédio dos autos de exibição e apreensão (fl. 32) e de constatação preliminar (fl. 33), ilustrado com foto (fl. 34) bem como e, principalmente, pelo laudo de exame químico-toxicológico realizado na substância entorpecente apreendida (fls. 73/75), que confirmou tratar-se de cocaína, causadora de dependência física ou psíquica, listadas na Portaria n. 344/98 SVS/MS (fl. 74).

A autoria, da mesma forma, não comporta dúvidas.

Vale lembrar, em primeiro lugar, que o acusado foi preso em flagrante, em local conhecido como "ponto" de venda de entorpecentes, surpreendido fugindo e se desfazendo de uma sacola contendo diversos entorpecentes em seu interior, razão pela qual a autoria se torna certa, pois, segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho, a prisão em flagrante "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra "Do Flagrante Delito", 1933, p. 25.

De acordo com HÉLIO TORNAGHI, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor: "Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" ("Curso de Processo Penal", 5ª ed., 49).

Ademais, a análise coligida dos elementos colhidos no caderno investigativo e produzidos sob o crivo do contraditório permite concluir pela responsabilidade penal do agente. Vejamos.

Ivan Cássio Cimenton, policial militar, contou que na data dos fatos estava em

patrulhamento, quando recebeu uma "denúncia" de que naquele local, tratando-se de um matagal à beira do rio, estava ocorrendo tráfico de drogas. Então, houve uma divisão de equipes e, no local, o réu avistou a chegada dos policiais e fugiu pela mata, em poder de uma sacola plástica nas mãos. Houve o cerco, sendo ele abordado, não na posse da sacola plástica. Indagado, apesar de inicialmente negar, resolveu indicar o local em que havia enterrado aquela sacola plástica, que fora localizada contendo aproximadamente 130 pinos de cocaína, em cores distintas. ELIAS, conhecido dos "meios" policiais desde quando era adolescente, época em que chegou a ser apreendido por ato infracional, confessou informalmente que estava ali para realizar o tráfico de drogas, recebendo R\$150,00 por dia de trabalho.

Clayton Luis dos Santos, policial civil, disse que o local dos fatos era um "ponto" de tráfico, com alternância diária de vendedores de droga. Naquela data, os policiais militares avistaram ELIAS com uma sacola na mão, tentando se evadir. Abordado, o réu mostrou onde havia se desfeito da sacola contendo drogas. Informalmente, o acusado confessou para o depoente a destinação mercantil daqueles entorpecentes, sendo a terceira vez que comercializava, recebendo R\$150,00.

Diversamente da postura adotada em solo policial (fl. 06), quando confirmou a propriedade de todo o entorpecente apreendido, mas sustentou ser para consumo pessoal próprio, interrogado em Juízo ELIAS negou qualquer vínculo com aqueles pinos de cocaína. Alegou que ter se dirigido até lá, com R\$10,00, para adquirir uma porção de "maconha" e, chegando ao local, os policiais apareceram, tendo as quatro ou cinco pessoas ("meninos") corrido e jogado a sacola. Assustado, o interrogando também fugiu, mas na direção da polícia, sendo, então, abordado, sem nada de ilícito em seu poder. Em vistoria, os policiais localizaram uma sacola contendo entorpecentes, a qual não lhe pertencia. Questionado pontualmente, negou o teor do seu interrogatório policial que consta dos autos. Ao final requereu uma "medida protetiva" (sic) para ser isolado dentro do estabelecimento prisional em que está recolhido, alegando estar "correndo risco de vida" (sic) por disputa de facção criminosa.

Pois bem. Este é o contexto instalado nos autos.

Com efeito, os policiais que atuaram na ocorrência demonstraram muita segurança em seus relatos, apresentando detalhes substanciais que evidenciam conhecimento do caso e precisão quanto à dinâmica fática. Em versões harmônicas, atribuíram ao acusado a prática delitiva.

Segundo se depreende da análise coligida dos depoimentos, policiais militares, após receberam informações a respeito da comercialização de entorpecentes em um matagal, à margem do rio, local já conhecido como "ponto" de venda, formaram equipes e para lá se dirigiram. Então, visualizaram o réu, já conhecido nos "meios" policiais desde à época em que era adolescente, sozinho, esboçando reação corporal anômala ao avistar a viatura, tentando fugir para na direção do matagal, em poder de uma sacola plástica. Ele foi perseguido, mas ao tempo da abordagem, já não mais estava em poder da sacola.

Ato contínuo, o réu foi indagado e, após inicialmente negar, veio a informar aos policiais o local em que a havia escondido aquela sacola, sendo, então, localizada e identificada contendo mais de 130 pinos de cocaína, coloridos, todos prontos para comercialização, conforme bem retrata a fotografia de fl. 34.

Informalmente, segundo os policiais, ELIAS teria confessado a propriedade e o destino mercantil que conferiria para aqueles entorpecentes, acrescentando ser a terceira vez que estava vendendo entorpecentes e receberia R\$150,00.

Detido, em solo policial foi interrogado formalmente e confirmou a propriedade daqueles pinos apreendidos, pontuando, todavia, serem para consumo pessoal próprio, mas em Juízo modificou sua postura, apresentando versão desvencilhadora, por

completo, daquela droga.

Contudo, diversamente dos retilíneos depoimentos dos policiais, o réu alterou sua versão sem justificativa.

Ora, negando o teor daquele interrogatório prestado em solo policial, não há campo para se concluir que a D. Autoridade Policial "inventou" ser ele o proprietário de todos os entorpecentes, mas sem lhe imputar, também falsamente, a destinação mercantil e, sim, fazer constar que seria "apenas" para consumo pessoal.

Apresenta-se comum que detidos permaneçam em silêncio ao tempo do interrogatório policial, fazendo uso do direito que lhes é assegurado constitucionalmente. Em sendo assim, não há como interpretarmos que a D. Autoridade Policial inventou o teor daquele depoimento apenas para atribuir-lhe a propriedade da droga, mas sem lhe imputar também a traficância.

Outrossim, a suposta intenção do acusado ao se dirigir até aquele ponto para adquirir uma porção de "maconha" e, no local, existirem outras pessoas, que fugiram com a aparição dos milicianos, não conta com indícios mínimos nos autos, quiçá provas.

Isto porque, além de tal cenário fático ter sido trazido à tona somente ao tempo do interrogatório judicial, sem qualquer testemunha arrolada, os policiais foram seguros quando destacaram que ELIAS era a única pessoa presente ao tempo da chegada e investida, sendo o momento em que visualizaram a sacola plástica em suas mãos, posteriormente localizada com o auxílio dele.

Lembro, ademais, que o réu já era conhecido nos "meios" policiais, contando com envolvimento infracionais anteriores, ao tempo da sua adolescência e, quando questionado em seu interrogatório judicial, apresentou a mesma tese de usuário.

Sempre a droga apreendida em seu poder, na sua visão, é para consumo pessoal próprio.

E não é só.

Liberado da Fundação Casa em junho/2022, veio a ser preso em flagrante (penalmente imputável), singelos dois meses depois, estando em uma "biqueira" e trazendo consigo uma sacola plástica contendo 135 pinos de cocaína.

Nesse contexto, não há dúvidas de que aqueles entorpecentes, pelas circunstâncias fáticas-geográficas, natureza, forma de acondicionamento e, principalmente quantidade, se destinavam ao tráfico, prática que o réu estava reiteradamente envolvido.

Ademais, ao final do seu interrogatório demonstrou certa preocupação ao postular "medidas protetivas" sob a justificativa de estar correndo risco de morte por desavença de facção criminosa, cenário comumente visto às pessoas que estão intrinsecamente vinculadas a práticas criminosas.

Não há campo para a pretendida desclassificação. Com efeito, inexistem elementos indicativos de ser ele mero usuário e de que aqueles entorpecentes, naquelas circunstâncias fáticas, forma de acondicionamento e quantidade, se destinavam exclusivamente ao seu consumo pessoal.

E como também reconhecem os tribunais:

"Não cabe a desclassificação do delito de tráfico ilícito de substância entorpecente, para o delito de uso indevido, quando ausente a prova, a cargo da

defesa, da exclusividade do uso próprio. "(RT 710/325).

Destarte, ante a valoração dos elementos fáticos probatórios, inviável o pedido de absolvição do réu, eis que os argumentos lançados são frágeis, sobretudo diante do contexto criminoso em que estava inserido.

Nesse passo, anoto que a conduta de trazer consigo não afasta a violação ao art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pois, para a consumação do crime prescinde de atos de comercialização, porque se trata de dispositivo de conteúdo variado, ou de ação múltipla, ensejando a prática do delito, em questão, a violação a qualquer uma das suas várias condutas.

É evidente que o tráfico de entorpecente envolve atividades essencialmente clandestinas, daí a razão da não exigência da prova flagrancial do comércio ilícito, mas elementos, concretos, que forneçam a evidência do comércio.

Outrossim, já se decidiu que "para a formação do juízo de certeza razoável sobre o comércio de drogas de agente devidamente processado, não é indispensável à prova efetiva do tráfico. Tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente...".

Frise-se, ainda, já se decidiu que, "para se identificar o traficante e distingui-lo do usuário, não é só o problema da quantidade que se deve levar em conta. Os próprios traficantes raramente são encontrados com grandes quantias de tóxicos, pois se de um lado não pretendem correr o risco de perder tudo, numa investida policial, ou de outro a pequena quantidade pode prestar-se a vendas a varejo e mesmo a dissimulação do característico de mercancia" (Vicente Grecco Filho, in "Tóxicos", 1993, Editora Saraiva, n. 17, pág. 120, destaquei).

Sendo assim, as circunstâncias fáticas e a prova oral colhida se mostram suficientes para a condenação do réu pelo delito de tráfico de entorpecentes, não havendo campo para a pretendida desclassificação para o crime de porte de entorpecentes (artigo 28, caput, da Lei 11.343/06).

O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade a ser reconhecida, razão pela qual a condenação e imposição da correspondente reprimenda estatal por este delito são medidas que se impõem.

PASSO À DOSAGEM DA PENA.

Atento às diretrizes previstas no art. 59 do Código Penal e da análise da Certidão de Eventos de fl. 36), verifico que o acusado é primário e não ostenta antecedentes conhecidos. Da mesma forma, à luz do art. 42 da Lei de Drogas também não vislumbro a presença de circunstâncias judiciais desabonadoras, razão pela qual a pena-base poderá permanecer no mínimo legal.

Ausentes agravantes, presente a atenuante do art. 65, I, do CP, eis que ao tempo do fato o réu era menor de 21 anos, cuja redução de 1/6 (um sexto), todavia, resta prejudicada, em razão da pena-base já estar no patamar mínimo (Súmula nº 231 do STJ).

Inexistem causas de aumento e/ou de diminuição. Justifico.

Não campo para a aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Justifico.

O réu conta com 18 anos de idade (fl. 10) e, num passado bem recente, já respondeu a diversos atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas (fl. 37), revelando ser uma prática reiterada em sua vida, ma medida em que, ao atingir a

maioridade, permaneceu se enveredando à essa odiosa atividade ilícita.

Importuno ressaltar que os ato infracionais indicados são perfeitamente aptos a afastarem a incidência da minorante em questão, na medida em que permite concluir que ele se dedica à atividade criminosa.

Neste sentido, recente julgado do C. STJ:

"2. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 3. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidencia a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes da Quinta Turma." (HC 364837/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 01/02/2017).

O E. TJSP também trilha o mesmo posicionamento: Acórdão 1276435,07377436720198070001, Rel. Mario Machado, 1ª Turma Criminal, j. 20/08/2020, p. 1/9/2020; Acórdão 1253710, 00084260220188070001, Rel. Cruz Macedo, 1ª Turma Criminal, j. 28/05/2020, p. 10/06/2020; Acórdão 1263636, 00027059720198070001 Rel. Jair Sores, 2ª Turma Criminal, j. 9/7/2020, p. 22/7/2020, Acórdão 1272019, 0011696820178070001, Rel. Waldir Leôncio Junior, 3ª Turma Criminal, j. 06/08/2020, p. 15/08/2020)

Efetivamente, no caso em apreço, sem quaisquer dúvidas, o réu, que trazia consigo considerável quantidade de pinos de cocaína (135), estava envolvido com a atividade criminosa.

No que tange ao regime penitenciário, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e os a ele equiparados foi declarada inconstitucional pelo Col. Pretório Excelso, em 27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 11.840/ES, no Pleno, rel. Min. Dias Toffi.

Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. 33, §2º e 3º do Cód. Penal, bem como do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei (STJ HC 272.152/SP rel. Min. Marilza Maynard 6ª Turma J. 10.12.2013).

No caso em testilha, o regime para cumprimento da pena privativa de liberdade, não pode ser outro que o INICIAL FECHADO, até porque, as medidas socioeducativas de internação na Fundação Casa aplicadas, mesmo implicando restrição de liberdade, não serviram para alcançar a esperada ressocialização, de forma que outro regime prisional, diferente do mais gravoso, tende a esvaziar as finalidades da reprimenda, permitindo-se um retorno precoce à sociedade.

NÃO campo para a aplicação do artigo 387, §2º, do CPP, devendo a progressão do regime ser analisada pelo juízo da execução, competente para tanto, na medida em que detém as informações necessárias, sob os prismas objetivo (cálculo de pena) e subjetivo (comportamento carcerário) para enfrentar a questão.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia para CONDENAR o réu ELIAS JOSÉ CARVALHO CÂNDIDO, qualificado nos autos, a cumprir pena de 05 (cinco) anos, de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo da data dos fatos, com correção monetária na fase executória, na forma do §2º do art. 49, por infração ao delito previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06.

INCABÍVEL a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,

devido a quantidade total de pena sopesada (art. 44, I, CP) e em razão de o réu não acumular aspectos subjetivos favoráveis (III).

O réu permaneceu preso durante a instrução processual. E, presentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva, em especial à aplicação da lei e a garantia da ordem pública (art. 312, caput, cc. 313, ambos do CPP) – lembrando que ele foi liberado da Fundação Casa em junho/22 e singelos dois meses depois, já maior de idade, veio a ser preso em flagrante novamente por envolvimento com o tráfico -, agora, frente ao édito condenatório, com elevada pena a ser cumprida em regime prisional mais gravoso, com maior razão, deverá aguardar preso a fase recursal (art. 387, §1º, CPP).

Recomende-se o réu, com as observações já realizadas ao término da audiência de instrução (vide ata de fl. 115).

Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas que ainda não tenham sido incineradas, oficiando-se.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, expeça-se carta de guia de execução (Súmula nº 716, do STF) e anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ).

P.R.I.C.

Amparo, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA